

1508971-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... na denúncia, configurando-se os delitos de roubo majorado e extorsão, igualmente majorada. Nesse ponto, a negativa do réu quanto ao crime de extorsão está isolada no contexto probatório.

Não se pode olvidar que a vítima, inquirida em audiência, reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo e extorsão, ainda que colocado ao lado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508971-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508971-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104246/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 24339511 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2104246 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO 3 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

AURIVAN ANDRÉ SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I e no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 04h00min, na Rua dos Pinheiros, Alto de Pinheiros, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos não identificadas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo Jeep Renegade, de placas RTG7H95, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R\$ 37,10 de propriedade da vítima Gilberto

Lima Santos Filho.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias supra, o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras três pessoas ainda não identificadas, constrangeu Gilberto Lima Santos Filho, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer senhas de acesso aos aplicativos bancários instalados no aparelho, sendo que o crime foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls. 53/55).

A denúncia foi recebida aos 02 de maio de 2022 em fls. 78.

Citado em fls. 84, o réu ofereceu resposta escrita em fls. 88.

Em instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado, ao final.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova produzida em Juízo e entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restou comprovada, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, pugnando pela consideração de sua reincidência para exacerbação da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, ante a fragilidade probatória, especialmente diante da nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Pleiteou o reconhecimento do delito único de roubo, afastando-se o crime de extorsão, sob alegação de inexistência de conduta ativa da vítima, bem como por não haver promessa de mal futuro à vítima, mas atual, tendo havido ofensa a um único bem jurídico, consubstanciado no patrimônio da vítima. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, com fração mínima de aumento, a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, o afastamento da majorante do § 1.º do artigo 158 do Código Penal, o reconhecimento da confissão, a fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19), pelo auto de reconhecimento positivo de fls. 22 e pelos depoimentos orais colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, também é certa, devendo ser atribuída ao réu.

A testemunha Paulo José Bonifácio Fonseca Novaes disse que recebeu via rádio a notícia de sequestro, praticado por um veículo Renegade escuro, não foi informado o emplacamento a princípio. Patrulhando próximo ao local do sequestro, avistou o veículo. Após alguns minutos de acompanhamento, o veículo bateu em um poste. O indivíduo saiu correndo, foi perseguido a pé e detido. No bolso dele foi encontrada quantia em dinheiro. Fez contato com a vítima apenas no DP. Vítima contou que era Uber e foi abordada por dois indivíduos, os quais exigiram o celular para tentar fazer transações, mas a vítima deu as senhas erradas. O veículo Renegade era alugado pela vítima. Não se recorda se a vítima comentou sobre o uso de arma, mas disse que permaneceu com a liberdade restrita por cerca de uma hora. Cerca de uma hora depois da comunicação via rádio é que o veículo Renegade foi visto.

A testemunha Wedson Pereira dos Santos corroborou o relato do colega de farda, acrescentando detalhes quanto ao percurso feito durante a perseguição. Ele bateu o veículo e fugiu a pé, tentou se esconder na residência, pulando um muro. Não perdeu o réu de vista em nenhum momento durante a perseguição. O réu disse que levaria o veículo para o Grajaú. Nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo.

Salvo engano, havia uma quantia de R\$ 32,00 com o réu. A vítima foi até o local onde estava o veículo e reconheceu o carro. A vítima não viu o réu no local dos fatos, apenas na delegacia, tendo-o reconhecido ali, formalmente. A vítima disse que fora abordada por dois indivíduos, inicialmente, armados. Rodaram por algum

tempo e pararam perto de um escadão, onde apareceu um terceiro indivíduo. O réu aqui presente deixou o local com o veículo, tendo a vítima permanecido com os outros dois indivíduos. A vítima disse que permaneceu em poder dos indivíduos por cerca de duas horas. Em determinado momento eles se distraíram e a vítima conseguiu fugir e pedir auxílio em uma base policial

A vítima Gilberto Lima Santos Filho apontou o indivíduo número 2. Foi abordado na região de Pinheiros, estava parado no farol quando dois indivíduos se aproximaram e o abordaram, um deles com uma arma, mandaram que ele fosse para o banco de trás. Isso aconteceu por volta de 0h50. O motorista estava com fone de ouvido e durante todo o trajeto ficava falando com alguém. Foi levado para a região do Capão Redondo, próximo de uma viela desceram do carro e se aproximaram outros dois indivíduos, um deles forte e gordo. Ele tinha um tablet, já com seus dados, e passou a exigir a senha da conta Nubank, a vítima passou, mas não conseguiram acesso. Durante o trajeto de carro um dos roubadores ficou mexendo em seu celular e acabou bloqueando os aplicativos, razão pela qual não chegaram a se realizar quaisquer transferências. Os três indivíduos deixaram o local com seu veículo, o quarto permaneceu com a arma apontada para a vítima. Permaneceu na viela por cerca de 1h30, em determinado momento viu um clarão, então o indivíduo que estava com ele achou que fosse a polícia e fugiu. A vítima buscou ajuda de uma pessoa que passava pelo local, que o levou para um posto policial. Cerca de meia hora depois de ter chegado a esse posto foi informado que o seu veículo havia colidido com outro, sofrendo perda total. O indivíduo hoje reconhecido estava sem máscara, era o que tinha assumido o volante do carro. Na delegacia fez o reconhecimento por um vidro, o réu estava sozinho ali, não havia outros indivíduos para comparação. . Levaram seu celular e R\$ 77,00 em dinheiro. O aparelho celular foi recuperado depois de 3 semanas, e o indivíduo que estava com o aparelho foi por ele reconhecido na delegacia como a pessoa que ficou no banco de trás com ele, prendendo-o. O indivíduo que hoje reconheceu estava com um fone de ouvido e recebia instruções ao dirigir o veículo.

Ao ser interrogado em sede policial, o acusado confessou parcialmente os fatos (fls.11).

Em juízo, o réu admitiu apenas a prática do roubo. Disse ter abordado a vítima para subtrair seu veículo. Assumiu a direção do veículo da vítima, mas não exigiu senhas, e nem viu o comparsa exigir. Não havia arma de fogo, mas apenas simulacro. Já foi condenado por receptação e por roubo, cumpriu as penas. Estudou até o primeiro ano do segundo grau. Trabalhava como eletricista e instalador, ganhava cerca de R\$ 2.000,00 por mês.

Como visto, ao contrário do alegado pela defesa, as provas existentes nos autos evidenciam a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia, configurando-se os delitos de roubo majorado e extorsão, igualmente majorada. Nesse ponto, a negativa do réu quanto ao crime de extorsão está isolada no contexto probatório.

Não se pode olvidar que a vítima, inquirida em audiência, reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo e extorsão, ainda que colocado ao lado de outras duas pessoas com características semelhantes.

Da mesma forma, a vítima realizou o reconhecimento pessoal em sede policial.

Destaque-se, nesse ponto, que a alegada nulidade do reconhecimento pela vítima efetuado na fase policial, por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de macular a prova produzida sob o crivo do contraditório. Nesse passo, firme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento dos tribunais superiores, consoante julgado abaixo destacado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades

do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou

o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece

meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima. Acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma contra a vítima, subtraiu, para si, um par de tênis, uma bermuda e a quantia de R\$ 50,00 em espécie, pertencente ao estabelecimento comercial "Loja do Japonês". Reconhecimento fotográfico e pessoal positivos na fase inquisitiva, bem como pessoal na fase judicial. Coesos relatos da vítima, bem traduzindo a verdade formal, comprovaram a ocorrência de subtração com grave ameaça. Idoneidade dos relatos da vítima. Precedentes. Inviável absolvição. 3. Dosimetria. Pena-base que merece pequeno reparo, para afastar o aumento imposto, fixando-a, então, no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. Parcial provimento, afastada a preliminar". (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0004102-65.2015 - j. 30/09/2020. Ressalta-se que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e merece maior valoração, notadamente quando descreve com precisão a dinâmica criminosa. Na hipótese dos autos, o firme reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima é reforçado pelos demais meios de prova acostados aos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que localizaram o veículo da vítima sendo conduzido pelo acusado e a confissão espontânea do réu, em Juízo. Assim, verifica-se que o acusado, ao ser apresentado à vítima, foi reconhecido sem sombra de dúvidas, como um dos indivíduos que entrou no veículo e inicialmente abordou a vítima. Asseverou que o réu foi o responsável por assumir a direção do veículo. A vítima mencionou, ainda, que durante o trajeto, foi compelida a fornecer suas senhas bancárias aos agentes, notou que estes eles mantinham contato telefônico constante com outras pessoas. Ademais, ao desembarcarem do veículo, a vítima foi compelida a novamente fornecer sua senha bancária, o que somente não ensejou a transferência de valores de suas contas bancárias porque houve bloqueio dos dispositivos pela instituição bancária. c

Afastadas, portanto, as alegações defensivas quanto à autoria e materialidade dos delitos, inexistem dúvidas de que o crime de roubo consumou-se, já que houve a inversão da posse do aparelho celular, quantia em dinheiro e veículo da vítima. Evidenciado, ainda, que o acusado e seu comparsa, inicialmente, privaram a vítima de sua liberdade, na medida em que a mantiveram em seu poder e presa dentro do veículo para que pudessem realizar a subtração do celular e do veículo e garantir a posse do produto do crime, ressaltando que a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que ficou encostada na vítima durante todo o trajeto. A vítima permaneceu no veículo até ser deixada em outro local, onde continuou sob a mira de arma de fogo, com sua liberdade restrita. Assim, ficou evidenciado que o ofendido teve liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, mais de três horas, além do suficiente para a tomada do delito, caracterizando a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal.

Todavia, deve ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Embora a prova oral seja clara no sentido de que foi utilizada uma arma para a prática das subtrações, a falta de apreensão da arma impede a constatação acerca de seu potencial lesivo. Vale dizer, a arma poderia até mesmo ser um simulacro, o que de plano impediria a majoração da pena. No entanto, ainda que ineficaz para a configuração da causa de aumento de pena, o fato de ter o réu utilizado arma para a prática dos delitos será levado em conta na primeira fase da fixação da pena, pois se trata de circunstância que facilitou a prática do crime, à medida que infundiu nas vítimas maior temor.

No mais, inviável o pleito defensivo para afastamento do delito de extorsão, reconhecendo-se o crime único de roubo. Isso porque foi evidenciada nos autos a consumação de dois delitos distintos e autônomos, ainda que praticados no mesmo contexto fático e tendo por objetividade jurídica o patrimônio da vítima. Cabe destacar, quanto à consumação do crime de extorsão, a despeito dos diversos posicionamentos jurisprudenciais, adota-se o entendimento que a extorsão ocorre quando a vítima pratica a ação, omissão ou tolerância coativamente impostas. E o ofendido foi efetivamente compelido a fornecer a senha de seu aparelho celular e aplicativos bancários, sob constantes ameaças, daí a conduta ativa da vítima, a

qual serve à caracterização do delito tipificado no artigo 158, do Código Penal. No caso, da prova produzida restou indubitável que a vítima efetivamente entregou ao réu e seus comparsas suas senhas de aplicativos bancários, em atos tipicamente colaborativos. Inequívoco que ela foi compelida a fazê-lo, sob ameaça, não se podendo qualificar tal conduta como passiva. Destaque-se, ainda, que o fato de não terem sido transferidas quantias da conta da vítima não afasta a consumação do delito, verificado no momento da entrega das senhas, pois o delito de extorsão classifica-se como formal. Vale dizer, a A efetiva lesão patrimonial caracterizaria, na hipótese, mero exaurimento do delito.

Ademais, ficou amplamente demonstrado o concurso de agentes para a prática delitiva, bem como que a vítima teve restringida sua liberdade e foi intimidada a efetuar a entrega das senhas de cartões e aplicativos. A restrição de liberdade foi, então, o meio de que se valeram o réu e seus comparsas para a obtenção de vantagem econômica indevida.

Configurada, portanto, a forma qualificada prevista no §3º do artigo 158 do Código Penal, plenamente compatível com a causa de aumento disposta no §1º, do referido artigo, eis que a mera localização topográfica não tem o condão de afastá-la.

Tem-se, portanto, inviável o reconhecimento de crime único, com absorção do delito de extorsão pelo crime de roubo. Embora cometidos no mesmo contexto fático, os delitos resultaram de diferentes desígnios e se materializaram em ações autônomas, restando evidente da prova colhida que houve efetivamente dois delitos distintos, sendo um de roubo e outro de extorsão, ambos com suas respectivas qualificadoras. Finalmente, imperioso o reconhecimento da figura do crime continuado, afastando-se a hipótese de concurso material postulada pelo representante ministerial. Da prova colacionada aos autos verifica-se que, embora configurando ações autônomas e figuras penais distintas, indubitável que os crimes se deram em continuidade delitiva, pois praticados no mesmo contexto fático, nas mesmas circunstâncias e com iguais modos de execução, evidenciando-se que o segundo deles era continuação do primeiro. Nesse passo, sendo ambos delitos contra o patrimônio, previstos no mesmo título penal, cabível a aplicação do comando do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, devidamente configurados nos autos os delitos de roubo e extorsão, com suas causas de aumento e qualificadoras, ainda que na forma continuada, passo à dosimetria das penas.

Primeiro para o crime de roubo.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, anoto que a circunstância de ter o réu utilizado arma para a prática do delito, gerando maior intimidação à vítima, justifica a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), ora fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.41 – processo 1505067-32.2021.8.26.0228), a qual compenso com a atenuante da confissão, mantendo a pena inalterada.

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e V, aumento a pena aplicada em 3/8, resultando em 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta do agente, que em razão da superioridade numérica e restrição da liberdade da vítima, majoraram o trauma por ela sofrido.

Não é o caso, portanto, de aplicação do aumento mínimo, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, consoante pleiteado pela defesa, pois haveria lesão ao princípio da individualização de pena. Nesse sentido:

"Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações no 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036.617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052.345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é

mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devam ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

"O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC no 76. 405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Crime de extorsão

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de circunstâncias que fazem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do §3º do artigo 158 do mesmo Código Penal, pelo que fixo a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.41 - processo 1505067-32.2021.8.26.0228), pelo que aumento a pena aplicada em 1/6, totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Configurada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 158, o que restou amplamente explicitado no corpo da decisão, aumento a pena em um terço, tornando definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Finalmente, diante do reconhecimento do crime continuado entre os delitos de roubo e extorsão, de rigor a majoração do mais grave deles, aqui considerado o de extorsão, com pena mais elevada, fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Para tanto, utilizo a fração de 1/3 para exasperação, conforme rege o art. 71, do Código Penal, observando que a fração mínima é incompatível com a gravidade concreta do caso em tela, envolvendo grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Resulta a pena final, portanto, em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Diante da pena aplicada, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido com o emprego de grave ameaça, não faz jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada.

Sendo assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando o montante da pena imposta, único aplicável na hipótese.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu AURIVAN ANDRÉ SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II e V e 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e à pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa, cada um no valor unitário mínimo.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que respondeu preso à imputação, sendo condenado ao cumprimento de pena em regime mais severo, sendo demonstrada a conveniência da manutenção de sua custódia, a fim de que se assegure a aplicação da lei penal.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.
Dê-se ciência à vítima.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA